

1500857-44.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500857-44.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500857-44.2022.8.26.0537 Controle nº 681/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL SANTOS DA LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DANIEL SANTOS DA LUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de abril de 2022, por volta das 07:30 horas, na Estrada Água Santa, altura do número 20, Bairro Pedreira, adquiriu, trazia consigo, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha e cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 47/50).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 103/104), sendo recebida a denúncia em 19.07.22

(fls. 108/109). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela agravante da reincidência, fixação de regime fechado, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º e o perdimento do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão e a fixação de regime semiaberto diante da detração penal. É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado negou a prática do crime (fls. 04), alegando que estava trabalhando apenas como "olheiro". Afirmou desconhecer os responsáveis pelo tráfico.

Em juízo, narrou que ia viajar para Mongaguá com sua esposa e amigos e comprou as drogas (pagou R\$210,00 por 25 porções de drogas) para levar. É usuário de drogas. O dinheiro apreendido em seu bolso era de sua rescisão, pois era registrado e trabalhava em uma metalúrgica. Estava na padaria tomando café e deixou as drogas junto do carro. Na fase policial negou e não falou que era "olheiro". Tem condenações por roubo e pelo art. 180 e estava em R.A. Conhecia os policiais de vista, porque passavam pelo local.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que realizavam operação de combate ao tráfico de drogas e trafegavam com a viatura pelo local dos fatos quando viram o réu em atitude suspeita. Relataram que observaram que alguns transeuntes se dirigiam até o réu, que passava algo para eles, que o guardavam no bolso, e depois entregavam outra coisa para aquele. Narraram que o réu se aproximou da roda de um veículo estacionado na via pública e apanhou uma sacola plástica amarela, momento em que o abordaram. Informaram que encontraram drogas na sacola e a quantia de R\$ 27,00 na posse do réu.

William (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico. Narrou que estavam em operação, avistaram o réu num canto na rua e o viram fazendo venda de drogas por duas vezes (pegava algo, atravessava a rua, abaixava, retirava algo junto do carro e entregava). O réu inicialmente falou que era "olheiro", mas depois que informou que viu movimento de venda, confessou o tráfico. No local que o réu abaixava achou uma sacola com drogas divididas em porções (maconha e cocaína). Tinha umas 20 ou 25 porções de drogas na sacola e em torno de R\$25,00 em dinheiro em poder do réu. Não foram abordados usuários, porque saíram para a direção contrária. Na rua há diversos comércios. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Adriano. O réu confessou a prática do crime após a apreensão das drogas. Não conhecia o réu anteriormente. O réu disse conhecia os policiais de vista, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 25 - 12 invólucros de maconha e 15 porções de maconha) e diversidade (maconha e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não

sendo provada a sua procedência, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (fls. 25 - 12 invólucros de maconha e 15 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico e inclusive os policiais presenciaram o mesmo vendendo. A negativa do réu está isolada, assim como sua versão de que estava trabalhando para o tráfico para o "olheiro", posto os policiais foram uníssonos no sentido de que as drogas foram apreendidas na sacola plástica que era manuseada pelo réu, que a guardava sob um veículo estacionado na via, e que presenciaram atos de mercancia, consistente na entrega de porções de entorpecentes a terceiros.

Ademais, o réu apresentou versões diversas nas duas fases, as quais são afastadas pelos uníssonos depoimentos dos policiais.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 29/31) e laudo definitivo (fls. 64/66). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 35 - proc. 400-94.2015; fls. 35/36 - proc. 802-46.2017). O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal).".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100). Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente".

As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo e receptação (fls. 35 - proc. 400-94.2015; fls. 35/36 - proc. 802-46.2017), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 28.04.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 27.08.2024).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DANIEL SANTOS DA LUZ à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que não há nada que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa, nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03 por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 25 e 63), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União. (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à sacola plástica de cor amarela apreendida (fls. 25), já periciada (fls. 95/97), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 51) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 27 de julho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA